

1502191-56.2021.8.26.0535

Classe: Auto de Prisão em Flagrante

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: NAIRA BLANCO MACHADO

Comarca: Arujá

Foro: Foro de Arujá

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 15/07/2022

... incide a causa de aumento por se tratar de tráfico entre Estados. Afirmou que a pena base deve ser exasperada ante a quantidade de drogas. Alegou ser inviável o reconhecimento de tráfico privilegiado, respondendo a ré por outro delito de tráfico de drogas, devendo ainda ser fixado no regime fechado.

Em alegações finais (fls. 159/172), a defesa da acusada alegou ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Arujá

Foro de Arujá

1ª Vara

Avenida Albino Rodrigues Neves, 394, Aruja - SP - cep 07400-000

1502191-56.2021.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1502191-56.2021.8.26.0535

Classe - Assunto

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ELISANGELA MARIA DA SILVA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). NAIRA BLANCO MACHADO

Vistos.

ELISANGELA MARIA DA SILVA, qualificada no autos, foi denunciada pela prática do crime descrito no art. 33, caput, c.c. art. 40, V, ambos da Lei 11.343/06, porque no 24 de agosto de 2021, por volta das 20:00 horas, à Rodovia Pres. Dutra, altura do KM 204, nesta cidade, transportava drogas, quais sejam, 30 tabletes de maconha, pesando 32,6 kg, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, caracterizando-se tráfico entre diversos estados da federação.

Narra a acusação que a acusada ocupava assento no ônibus recém saído da rodoviária Tietê, em São Paulo, com destino a Recife/PE. A acusada transportava em sua mala quantidade expressiva de drogas. O ônibus coletivo foi abordado por policiais rodoviários em patrulhamento de rotina, e durante as vistorias de praxe, cães farejadores apontaram a mala da acusada como suspeita, razão pela qual foi aberta. No interior da mala localizaram 30 tabletes de maconha. Ainda, foi apreendido um telefone celular e uma mala rosa, assim como R\$ 412,00. A acusada teria confessou a prática delitiva.

Auto de Prisão em Flagrante Delito às fls. 01. Boletim de Ocorrência às fls.. 05/07. Auto de exibição e apreensão às fls.08/09. Laudo de constatação (fls. 13/15).

A decisão de fls. 37/41 converteu o flagrante em prisão preventiva à acusada.

Notificada, a ré apresentou defesa preliminar às fls. 88/89.

A denúncia foi recebida em 15/10/2021, às fls. 94/95.

Folha de antecedentes às fls. 130.

Laudo definitivo toxicológico (fls. 132/134).

Em audiência foram ouvidas testemunhas e interrogadaa acusada (fls. 155/158).

O Ministério Público em alegações finais orais, pugnou pela procedência da denúncia. Quanto à dosimetria, altercou que incide a causa de aumento por se tratar de tráfico entre Estados. Afirmou que a pena base deve ser exasperada ante a quantidade de drogas. Alegou ser inviável o reconhecimento de tráfico privilegiado, respondendo a ré por outro delito de tráfico de drogas, devendo ainda ser fixado no regime fechado.

Em alegações finais (fls. 159/172), a defesa da acusada alegou ausência de dolo, não sabendo a acusada que transportava algo ilícito. Subsidiariamente, requereu o reconhecimento de tráfico privilegiado, por ser a ré primária e não se dedicar a atividades criminosas ou pertencer a organização criminosa. Altercou sobre a possibilidade de progressão de regime e que o tráfico privilegiado não seria equiparado a hediondo. Requereu a aplicação de regime aberto, ou ainda, semiaberto. Requereu que seja deferido o direito da ré recorrer em liberdade, sendo ainda realizada a detração pena. Pugnou pela aplicação de pena mínima.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva deve ser julgada procedente.

A materialidade está demonstrada conforme boletim de ocorrência, laudo de constatação e definitivo e prova oral colhida.

Autoria da ré segue a mesma sorte.

Passo à análise da prova oral colhida no feito:

A testemunha Leandro da Silva declarou que estavam trabalhando numa operação com cães de faro na rodovia. Pararam um veículo que vinha de Curitiba para Recife e três cães indicaram uma mochila. Ao vistoriarem a mochila acharam 30 kg ou 30 pacotes de maconha. Na mochila tem uma identificação de passageiro e conseguiram identificar a mochila como sendo de Elisângela. Recorda-se que a ré disse que pegou a mala em Cotia, pegou um trem até Osasco e levaria a droga para Aracaju ou Recife, e receberia R\$ 3.000,00 pela entrega.

A testemunha Ricardo José Pires, policial rodoviário federal, disse que abordaram um ônibus que era São Paulo-Recife. Disse que em revista o cão deu indicação de uma mala e identificaram a ré. A ré confirmou que a mala era dela e que receberia R\$ 3.000,00 para levar para Aracaju. Dentro da mochila havia tabletes de maconha, com cerca de 30kg da droga. Não conhecia a ré antes dos fatos. Narrou que ao ser aberta a mala a acusada disse que ia fazer o transporte da mala. Ela sabia que havia algo que não era certo, mas não afirmou que era droga. Narrou que “mula” por tráfico é a pessoa que somente faz o transporte da droga. 100% das mulas sabem que transportam coisas ilícitas. A acusada seria “mula”, tanto que receberia dinheiro para levar a mala. Afirmou que não se recorda se ela sabia que era drogas, mas sabe que ela

tinha conhecimento que não era coisa certa. Esclareceu a testemunha que não se recorda se ela falou que tinha droga ou não, mas a ré lhe falou que sabia que era algo ilícito o que levava.

A ré Elisângela Maria da Silva declarou que tem 40 anos, é desempregada e estudou até a quarta série. Tem quatro filhos e não é casada. Os seus filhos são maiores de idade. Teve processo anterior de "portaria", referente a visitas que fazia ao seu ex-marido quando preso, tendo "caído" na portaria. Afirmou que não tinha ciência do que tinha na mala. Pessoa de nome "Dinho" ofereceu esse serviço e aceitou por estar passando necessidade. O "Dinho" disse que havia aparelhos telefônicos na mala. Encontrou essa pessoa num barzinho perto da sua casa e ele estava lá oferecendo aparelhos eletrônicos ao dono do bar. Essa pessoa viu que estava comprando fiado no bar e por isso ofereceu a ela o serviço. Não tem propriedades e mora de favor na casa de uma pessoa. Disse que queria responder na rua ou "pagando cesta".

Essa foi a prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

O acusado em interrogatório judicial confirmou que trazia uma mala consigo no interior do ônibus, alegando que a recebeu de pessoa de nome "Dinho", tendo aceitado realizar serviço para ele, e que tinha sido informada de que havia aparelhos telefônicos na mala. Sustentou que não sabia o que havia na mala que transportava.

Em sede policial, fls. 04, a ré apresentou versão distinta, alegando que pegou drogas na cidade de Cotia/SP, embarcando de trem para Osasco e que entregaria as drogas em Aracaju/SE. Por tal entrega receberia R\$ 3.000,00.

Os policiais rodoviários federais ouvidos como testemunhas narraram como se deu o encontro das drogas no interior da mala transportada pela ré, o que foi realizado com a ajuda de cães farejadores. O policial Leandro, inclusive, indicou que a ré teria mencionado ter pego a mala em Cotia.

Anoto que o exame toxicológico confirmou a natureza entorpecente das drogas localizadas (fls. 132/134).

Vê-se que a prova amealhada durante a instrução penal é suficiente para o reconhecimento do crime de tráfico de drogas pela acusada.

Também comporta acolhimento o reconhecimento de causa de aumento de pena do art. 40, V, da Lei de Drogas, pois o ônibus se dirigia para o estado de Pernambuco e os policiais ouvidos como testemunhas afirmaram que a ré teria alegado a eles que iria para a cidade de Aracaju. Ainda, em delegacia, a ré também confirmou que se dirigia para Aracaju para realizar a entrega da droga.

Com efeito, embora não se possa utilizar elementos do inquérito policial como prova, no caso em questão, é a própria versão da acusada em juízo que, contraposta aos relatos dos policiais e às demais provas colhidas, termina por conduzir à certeza de culpabilidade.

Este juízo vem sempre consignando que não seria demais exigir do órgão acusador, a quem se impõe o ônus probandi, a juntada de outras provas que não se limitem às declarações dos policiais que foram responsáveis pela prisão do agente, e que hoje já existem outros instrumentos e mecanismos aptos a robustecer os motivos ensejadores da prisão e da persecução penal, como gravações audiovisuais para registrar as abordagens, diligências e operações. Não obstante, as circunstâncias específicas do caso, mormente em relação às declarações da acusada, que apresenta em juízo versão diversa do que alegou em delegacia, assim como os relatos de policiais, e o encontro da droga em mala trazida com a ré, revelam uma versão defensiva frágil e pouco convincente, a qual, por sua vez, acaba oferecendo elementos sobre a abordagem que se coadunam com a dinâmica relatada de forma

uníssona pelos policiais, terminando por constituir um conjunto probatório suficiente à prolação de um decreto condenatório em desfavor da acusada, com o reconhecimento da causa de aumento apontada.

Nota-se que a acusada agiu com dolo, não podendo ser acolhida a tese da defesa de que inexistiu conduta ilícita por desconhecer a ré o conteúdo da mala. Vê-se que a versão da acusada de que não sabia que transportava maconha não se mostra crível, não tendo trazido a acusada qualquer elemento de prova passível de gerar alguma dúvida no tocante a sua culpabilidade, e com isso, ensejar a aplicação do princípio *in dubio pro reo*.

Conforme acima aludido, em sede policial (fls. 04), a ré confessou que realizava transporte de drogas para outro Estado da Federação. Ainda, o policial ouvido como testemunha narrou ter dito a ré, quando abordada, ter conhecimento de que transportava algo que não seria certo.

Nota-se que a acusada agiu, no mínimo, com dolo eventual, uma vez que ela mesmo teria confirmado aos policiais, quando abordada, que poderia existir algo de errado no conteúdo da mala.

Neste sentido:

Apelação. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Preliminar. Alegação de inépcia da denúncia. Mérito. Pedido de absolvição por insuficiência probatória. Pleitos subsidiários: a) redução do aumento operado na primeira fase; b) aplicação do redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, no patamar máximo. 1. Alegação de inépcia da denúncia. Não acolhimento. Denúncia suficientemente detalhada com descrição pormenorizada das condutas atribuídas aos réus. Indicação do objeto material do tráfico e das circunstâncias de tempo e local. 2. Associação para o tráfico de drogas. Delito não comprovado. Estabilidade e permanência que não se inferem dos elementos coligidos aos autos. Absolvição que se impõe. 3. Tráfico de drogas. 3.1. Prova da materialidade e de autoria. Depoimentos dos policiais uniformes e convergentes ao longo da persecução penal. Presença de contradições nas versões apresentadas pelos réus, enfraquecendo-os de credibilidade. Conduta dirigida ao comércio espúrio. 3.2. Alegação de desconhecimento quanto ao conteúdo do porta-malas do veículo que conduziam. Versão fantasiosa dos réus que não se sustenta. Apreensão de vultosa quantidade de entorpecente que não poderia passar despercebida. 4. Dosimetria da pena que comporta reparos. 4.1. Aumento desproporcional da pena base. Quantidade de droga excessiva apreendida com os réus. Aumento em razão de uma única circunstância judicial desfavorável. Readequação do aumento operado para o dobro acima do mínimo legal. 4.2. Aplicação da fração e 1/6 (um) sexto em razão do reconhecimento da reincidência do réu Jackson. 5. Do regime inicial para o cumprimento da pena. Fixação do regime fechado. Circunstâncias judiciais desfavoráveis que permitem a fixação do regime inicial mais rigoroso. 6. Recursos conhecidos e parcialmente providos. (TJSP; Apelação Criminal 1526141-16.2019.8.26.0228; Relator (a): Marcos Alexandre Coelho Zilli; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 13ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 15/06/2021; Data de Registro: 16/06/2021) (grifos nossos)

Recorda-se, ainda, que o crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06 é de ação múltipla, de modo que se consuma com qualquer das outras condutas descritas no mencionado dispositivo legal, como, transportar, trazer consigo, guardar, ter em depósito, entregar a consumo e fornecer drogas, ainda que gratuitamente. Nesse sentido:

"HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. TESES DE QUE A PROVA OBTIDA NOS AUTOS É ILÍCITA, E DE QUE O CRIME É IMPOSSÍVEL, POR NÃO TER CHEGADO AO DESTINO, QUE NÃO FORAM VENTILADAS NAS RAZÕES RECURSAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDUTA DE TRANSPORTAR OU TRAZER CONSIGO, COM O INTUITO DE FORNECER, AINDA QUE PARA GRATUITO CONSUMO ALHEIO, QUE SE SUBSUME AO TIPO PREVISTO NO CAPUT DO ART. 33, DA LEI N.º 11.343/06. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA E CONTEÚDO VARIADO. CONSUMAÇÃO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO. [...] 2. "Transportar", "trazer consigo" ou "fornecer ainda que gratuitamente" substância entorpecente ilícita são São Paulo núcleos do tipo do delito de tráfico de drogas - crime de perigo

abstrato, de ação múltipla e conteúdo variado, que se consuma com a prática de quaisquer das ações insertas no art. 33 da Lei Antidrogas. (HC 225555/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, j. em 09/12/2012).

Outrossim, da análise dos autos, é possível extrair que a ré agiu como transportadora eventual, não havendo indícios de que a acusada integre organização criminosa, pois para que isto fique manifesto, é necessário que se verifique espontânea vontade de integrar a associação, além de fazer da criminalidade seu meio de vida principal, com habitualidade criminosa, não sendo este o caso de pessoas que são ocasional ou eventualmente cooptadas por tais organizações a praticarem delitos específicos. Assim, à vista das circunstâncias explanadas, não sendo possível concluir ser a ré integrante de organização criminosa, não haveria motivos idôneos a afastar a incidência do parágrafo 4º do art. 33 da lei 11.343/2006 ao caso em questão.

Neste sentido é o entendimento jurisprudencial, senão vejamos:

Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que deu parcial provimento ao recurso especial da acusação para afastar a minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. Narra o impetrante, em síntese, que: a) o paciente foi condenado em primeiro grau à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas; b) entre a sua prisão em flagrante e o julgamento de recurso de apelação em que se buscava o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena, cumpriu-se integralmente a pena, tendo sido extinta sua punibilidade; c) sobreveio, então, o ato coator, dando-se sequência à execução da pena privativa de liberdade, redimensionada para 5 anos de reclusão. Busca-se a detração com a alteração do regime de continuação da execução. É o relatório. Decido. 1. Cabimento do habeas corpus: A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: "O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal." (HC 128693 AgR, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) "O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal." (HC 123430, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) "(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior." (HC 86367, Relator (a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) No caso concreto, extrai-se dos autos (eDOC 10, p. 74) que o ato coator transitou em julgado em 15.3.2018. Assim, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. 2. Contudo, no que se refere ao afastamento do redutor previsto no art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006, verifico a existência de constrangimento ilegal, passível de conhecimento de plano. No caso concreto, o paciente foi condenado, em primeira instância, pela prática do delito previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais decidiu pela manutenção do redutor com base nos seguintes fundamentos (eDOC 10, pp. 65-66): Em relação à terceira fase de aplicação da pena, pleiteou o Parquet o afastamento da causa de diminuição da pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, ao argumento de que o acusado se dedicava às atividades criminosas. Sem razão o órgão acusador. Compulsando detidamente os autos, verifica-se que embora Jean Carlos tenha sido surpreendido em flagrante após ter sido constatado pelo serviço de inteligência da Polícia Federal o transporte da droga, nada nos autos menciona a respeito de outras atividades ilícitas por ele praticadas. Não há informações nos autos no que tange às investigações anteriormente realizadas, limitando-se os agentes policiais a indicar a respeito apenas da apreensão. Ademais, a meu ver, é dever da acusação trazer para os autos,

de forma inequívoca, as informações que têm o condão de incrementar as penas, não havendo, no presente feito, qualquer anotação neste sentido. Assim, não havendo provas suficientes de que o acusado fazia do comércio ilícito seu meio de vida, dedicando-se à atividade criminosa, é possível afirmar que o caso presente se revele como uma ocorrência isolada, o que permite a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º da Lei de Drogas. 2.1. Como se nota, no que atine ao afastamento do redutor, a motivação do Superior Tribunal de Justiça está centrada na expressiva quantidade de droga, superior a 108 kg (cento e oito quilogramas) de cocaína, bem como na constatação da existência de “acordo de recebimento da importância de R\$ 2.000,00 a ser paga por terceiro” para transporte daqueles tabletes, tudo a indicar a dedicação do paciente a atividades criminosas (eDOC 10, pp. 41-42). Não obstante o alto poder lesivo do entorpecente apreendido, não é possível fazer tal ilação sem o suporte de outros elementos fático-probatórios. Segundo a jurisprudência do STF, “[a] quantidade de drogas não poderia, automaticamente, proporcionar o entendimento de que a paciente faria do tráfico seu meio de vida ou integraria uma organização criminosa” (RHC 138.715, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 09.06.2017). Com efeito, a quantidade e a natureza da droga apreendida não são fatores que, isoladamente, impedem a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006, notadamente se evidenciada, como no caso dos autos, a mera condição de transportador do paciente, bem como, a partir do que as decisões proferidas permitem observar, o preenchimento dos demais requisitos previstos na minorante. Afirmou o TJMG que “nada nos autos menciona a respeito de outras atividades ilícitas por ele praticadas”. O paciente foi flagrado transportando expressiva quantidade de cocaína, conduta pela qual receberia remuneração. Contudo, à míngua de outros elementos probatórios, não há qualquer indicativo de que integre organização criminosa ou se dedique à traficância habitualmente. A Segunda Turma do STF tem posição firme no sentido de que a condição de “mula” ou a mera alusão ao fato de ter efetuado o transporte de entorpecentes (ainda que entre Estados da Federação), por si só, não impede a incidência da minorante. Para fins de individualização da pena, a singela alusão genérica à importância dos transportadores na estrutura de uma suposta organização criminosa não preenche o figurino exigido pela ordem constitucional. Na mesma linha: “Incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas afastada pelas instâncias de mérito com amparo em mera conjectura ou ilação de que os pacientes integrariam organização criminosa, já que recrutados para transportar drogas ao exterior (mulas do tráfico). Inexistência de base empírica idônea. Constrangimento ilegal configurado. Habeas corpus concedido de ofício. (...) O exercício da função de mula, embora indispensável para o tráfico internacional, não traduz, por si só, adesão, em caráter estável e permanente, à estrutura de organização criminosa, até porque esse recrutamento pode ter por finalidade um único transporte de droga.” (HC 124107, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 04.11.2014, grifei). “PENAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE CONCEDEU O BENEFÍCIO NA FRAÇÃO DE 1/3. PRECEDENTES. 1. A não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de um conjunto probatório apto a afastar pelo menos um dos critérios, que são autônomos, descritos no preceito legal: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa. Nesse juízo, não se pode ignorar que a norma em questão tem a clara finalidade de apenar com menor grau de intensidade quem pratica de modo eventual as condutas descritas no art. 33, caput e § 1º, em contraponto ao agente que faz do crime o seu modo de vida, o qual, evidentemente, não goza do referido benefício (cf. justificativa ao Projeto de Lei 115/2002 apresentada à Comissão de Constituição e Justiça e de Redação). 2. No caso, o Tribunal de apelação afastou a referida minorante com base em argumentos genéricos e teóricos, desprovidos de qualquer elemento contido nos autos, senão no fato de a paciente ter sido condenada pela prática do crime de tráfico transnacional de drogas. Por outro lado, a sentença condenatória afirmou, de forma segura, a inexistência de prova apta a justificar a negativa da causa de diminuição. Precedentes. 3. Ordem

parcialmente concedida." (HC 124022, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015, grifei). Dito isso, não visualizo qualquer fundamento hábil a negar a incidência da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 ao paciente. 4. Posto isso, com fulcro no art. 192 do RISTF, não conheço da impetração, mas concedo a ordem de ofício para restabelecer a minorante, devendo a pena do paciente seguir os moldes fixados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Comunique-se, com urgência, ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais e à Vara de Execuções Criminais da Comarca de Juiz de Fora com cópia do inteiro teor desta decisão. Comunique-se, outrossim, ao Superior Tribunal de Justiça, para ciência. Brasília, 14 de fevereiro de 2020. Ministro Edson Fachin Relator Documento assinado digitalmente. (STF - HC: 181268 MG - MINAS GERAIS 0086299-90.2020.1.00.0000, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 14/02/2020, Data de Publicação: DJe-035 19/02/2020). (grifos nossos)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. AGENTE NA CONDIÇÃO DE "MULA". PLEITO DE DECOTE DESSA MINORANTE. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. 1. A orientação jurisprudencial desta Casa, na linha do entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de que "o fato de o agente haver atuado como 'mula' no transporte da droga não pode - como numa relação, pura e simples, de causa e efeito - levar à conclusão de que ele seria integrante de organização criminosa e, como tal, não seria merecedor da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. A diferenciação deve ser feita, inequivocamente, caso a caso, com base em elementos objetivos e concretos dos autos (REsp n. 1.365.002/MS, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 11/9/2017). 2. No caso dos autos, o colegiado estadual, respeitando os critérios legais estabelecidos pelo art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 e, ainda, com observância aos pormenores da situação concreta, entendeu que inexistiam nos autos provas que demonstrassem a dedicação do agravado às atividades criminosas ou de que integrasse organização criminosa, embora tenha sido apreendida grande quantidade de entorpecente, qual seja, mais de 32kg (trinta e dois quilos) de maconha. 3. Nesse contexto, para que fosse possível a análise da pretensão recursal de decote dessa minorante, seria imprescindível o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, o que é defeso em âmbito de recurso especial, em virtude do disposto na Súmula n. 7 desta Corte. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1532159 MT 2019/0190378-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 18/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2020). (grifos nossos).

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CRIME QUE DENOTA HABITUALIDADE DELITIVA. EVIDENCIADA AINDA A PERICULOSIDADE CONCRETA DO PACIENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em 13 de novembro de 2019, com pedido de liminar, em favor de Pedro Eduardo Costa de Oliveira, em face de decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza/CE. 2. Compulsando os fólios, depreende-se que não assiste razão à defesa, 1) seja porque entendo que a imputação realizada pelos órgãos persecutórios da integração do paciente à organização criminosa é suficiente para comprovar o seu perigo à ordem pública, em razão da habitualidade criminosa ser inerente a esse tipo penal; 2) seja porque entendo estar presente nos autos provas da sua periculosidade concreta; Senão vejamos. 3. A organização criminosa está relacionada à atuação da delinquência estruturada, que visa afrontar diária e habitualmente bens jurídicos fundamentais para o Estado Democrático de Direito. Assim sendo, o indivíduo que decide por livre e espontânea vontade integrar determinada associação, deve ser considerado como uma pessoa que faz da criminalidade seu meio de vida principal. Não estamos aqui a tratar das pessoas que ocasionalmente são cooptadas ou coagidas por essas organizações a

praticarem delitos específicos - como, por exemplo, nos casos das 'mulas do tráfico' -, mas sim daquelas que decidiram fazer parte permanentemente da organização, fazendo das práticas criminosas verdadeiras profissões. 4. Ora, a habitualidade criminosa é condição de existência, portanto, condição sine qua non de uma organização criminosa, sendo a jurisprudência uníssona quanto à necessidade de manutenção da prisão preventiva dos réus, cujos autos evidenciam a prática habitual de delitos. Precedentes do STJ. 5. Ainda que se diga que tal indivíduo não detém nenhuma função administrativa, de comando ou de gerência, ele é parte indispensável para o todo harmônico funcionar; e ainda se beneficia, mesmo que indiretamente, do produto oriundo das atividades criminosas diárias e habituais da empresa do crime. (...) 11. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de habeas corpus, nº 0632586-38.2019.8.06.0000, ACORDAM os desembargadores da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará, por maioria, em CONHECER do habeas corpus impetrado, mas para DENEGAR a ordem, nos termos do voto do relator. Fortaleza, 21 de janeiro de 2020 MÁRIO PARENTE TEÓFILO NETO Relator Designado (TJ-CE - HC: 06325863820198060000 CE 0632586-38.2019.8.06.0000, Relator: MARIO PARENTE TEÓFILO NETO, Data de Julgamento: 21/01/2020, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/01/2020). Grifo Nosso.

Assim, tratando-se de acusada primária (fls. 130), deve ser reconhecida a causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, pois a ré ostenta bons antecedentes e inexistem nos autos comprovação suficiente de que se dedique a atividade criminosa, ficando demonstrado pelas provas acostadas aos autos que a ré atuou evidentemente como "mula". Demais disso, a quantidade de drogas, embora seja considerável, não obsta o reconhecimento da minorante.

Nesse sentido, os arestos abaixo colacionados.

EMENTA HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E DIREITO PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MULA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Pertinente à dosimetria da pena, encontra-se a aplicação da causa de diminuição da pena objeto do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. Para verificar a adequação da causa de diminuição ao caso concreto, indispensável observar tanto as condições individuais do agente quanto as da conduta em concreto praticada, de todo incabível a concessão do benefício em caso de reincidência, maus antecedentes, dedicação a atividades criminosas ou participação em grupo destinado a esse fim. 3. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que 'o exercício da função de mula, embora indispensável para o tráfico internacional, não traduz, por si só, adesão, em caráter estável e permanente, à estrutura de organização criminosa, até porque esse recrutamento pode ter por finalidade um único transporte de droga', porquanto 'descabe afastar a incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 com base em mera conjectura ou ilação de que os réus integrariam organização criminosa' (HC 124.107/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 24.11.2014). 4. Na hipótese, proporcional e razoável a fixação da minorante no patamar de 2/3 (dois terços), considerada a inexistência de circunstância ou fato desabonador ensejador de aplicação de fração menor. Precedentes: HC 132.459/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, votação unânime, DJe 13.02.2017; HC 131.918/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, votação unânime, DJe 02.3.2016; e HC 123.534/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, votação unânime, DJe 10.10.2014. 5. Observados os parâmetros estabelecidos no HC 97.256/RS e no HC 111.840/ES desta Suprema Corte e

consideradas a aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, no patamar de 2/3 (dois) terços e "a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis", possível a fixação de regime prisional mais brando - aberto -, e a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. 6. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito, mas com concessão de ofício da ordem, para determinar que o Tribunal Regional Federal da 3ª Região proceda a nova dosimetria da pena, mediante a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, no patamar de 2/3 (dois terços), e reexamine, se o caso, a fixação do regime inicial de cumprimento da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. (STF - HC: 129449 SP - SÃO PAULO 0004774-62.2015.1.00.0000, Relator: Min. ROSA WEBER, Data de Julgamento: 14/03/2017, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-088 28-04-2017). (grifos nossos)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. AGENTE NA CONDIÇÃO DE "MULA". AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO INFERIOR AO MÁXIMO ACERTADA. 1. Na hipótese do tráfico ilícito de entorpecentes, é indispensável atentar para o que disciplina o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. 2. No caso concreto, o Tribunal de origem expressamente fundamentou a majoração da pena-base em 2 anos, com fundamento na natureza e quantidade de entorpecentes - 1920g de "cocaína", nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e art. 59 do CP, encontrando-se devidamente justificada e proporcional às especificidades do caso versado. 3. Para a aplicação da minorante do artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, é necessário o preenchimento de quatro requisitos cumulativos, quais sejam, primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso em concreto. O legislador, entretanto, não definiu os critérios a serem adotados pelo magistrado para a escolha do percentual de redução da pena. 4. No presente caso, a opção pela fração de 1/6 foi devidamente justificada no fato de o acusado ter contribuído com organização criminosa, agindo na condição de "mula", o que se mostra condizente com os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade e encontra justificativa nas peculiaridades da ação criminosa. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1013343/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 01/08/2017)

Oportuno ressaltar que a incidência de uma causa de aumento não é óbice ao reconhecimento de tráfico privilegiado.

A propósito:

Apelação - Tráfico interestadual em transporte coletivo - Conduta de transportar, para o tráfico, 24 tijolos de maconha (22,530 Kg) - Pleito absolutório por fragilidade probatória - Inadmissibilidade - Autoria e materialidade comprovadas - Depoimentos dos policiais firmes e coerentes, os quais consoam com a confissão judicial da ré - Validade para embasar decreto condenatório - Circunstâncias da prisão e quantidade de entorpecentes a demonstrar a destinação da droga à venda - Provas que bem demonstram as causas de aumento do artigo 40, III e V, da Lei de Drogas - Desnecessidade de que o tráfico tenha como alvo pessoas do transporte coletivo - Penas, todavia, que comportam alteração - Quantidade que, por si só, não afasta a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas - Ré primária - Não comprovação de envolvimento com atividades criminosas ou organização criminosa - Quantidade a impedir, todavia, a redução no patamar máximo, mostrando-se ajustada a redução mínima de um sexto - Abrandamento do regime prisional, do fechado para o

semiaberto – Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 1500089-91.2019.8.26.0483; Relator (a): Osni Pereira; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Presidente Venceslau - 3ª Vara; Data do Julgamento: 31/05/2021; Data de Registro: 31/05/2021)

Inexiste qualquer causa excludente de ilicitude ou que isente a ré de pena.

No mais, a ação foi culpável, reprovável, pois a ré era (e ainda é) ao tempo da conduta imputável, tendo consciência da ilicitude de suas ações. Não há, portanto, qualquer causa excludente da culpabilidade.

Isto posto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para o fim de condenar ELISANGELA MARIA DA SILVA, qualificada no autos, como incurso no art. 33, §4º, c.c. art. 40, V, todos da Lei 11.343/06.

Apurada a responsabilidade penal, passo a dosar a pena de condenação.

Circunstâncias judiciais

Assim, primeiramente, no tocante às circunstâncias judiciais, verifico que a ré agiu com a culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar nesse sentido. Não há nos autos elementos concretos que permitam uma valoração da sua personalidade. A ré não possui maus antecedentes (forçoso destacar que além do presente feito, a ré responde por outro processo criminal de tráfico, mas não há notícias nos autos de condenação, nem de trânsito em julgado - fls. 130). O motivo do delito se constituiu pela obtenção do lucro fácil, que já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito. Nada há, em concreto, que desabone a sua conduta social. As consequências do crime não se mostraram de maior monta. As circunstâncias se revelam desfavoráveis, diante da localização de mais de 32 quilos de maconha, tratando-se de quantidade bastante elevada de droga, autorizando, desta feita, um aumento da pena, a despeito de tratar-se de substância entorpecente, a princípio, menos lesiva quando comparada a outras substâncias ilícitas.

Diante disso, imponho à ré a pena-base de 07 anos de reclusão e 562 dias-multa, no menor valor legal.

Na segunda fase, observo estarem ausentes agravantes. Presente a atenuante da confissão, em sede policial, razão pela qual atenuo a pena da acusada, atingindo a pena intermediária 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 500 dias-multa.

Na terceira fase, presente uma causa de aumento (art. 40, inc. V, da Lei 11.343/06), devendo a pena ser aumentada em 1/6.

Presente, todavia, como já asseverado alhures, a causa de diminuição de pena do § 4º, art. 33, da Lei 11.343/06, uma vez que a ré é primária, não possuindo antecedentes, não havendo ainda provas suficientes de que se dedique a atividades criminosas ou de que integre organização criminosa, não tendo sido produzida pela acusação prova bastante de vínculo aprofundado e estável com o comércio espúrio, para cujo reconhecimento seria necessária a existência de prova cabal neste sentido.

Neste ponto, vale mencionar a manifestação de César Dário Mariano:

Presentes os requisitos previstos na norma a diminuição da pena é obrigatória, não ficando ao alvedrio do Juiz operar a redução ou não. Embora a norma empregue a expressão “as penas poderão ser reduzidas”, não se trata de atividade

discrecionária do Juízo, mas de direito subjetivo do acusado. Aliás, a primariedade e bons antecedentes deverão ser demonstrados pelo acusado, ao passo que caberá ao Ministério Público o ônus de provar que o réu se dedica à atividade criminosa ou que pertence à organização criminosa. Não cabe ao réu a prova de fatos negativos, mas a quem alega, no caso, o Ministério Público.

(...) Dedicar-se a atividades criminosas pressupõe reiteração de condutas tipificadas como crime, ou seja, habitualidade no cometimento de delitos. Tal circunstância poderá ser demonstrada por meio de folhas de antecedentes criminais, certidões cartorárias, cópias de outros processos, testemunhas, ou seja, qualquer meio hábil a provar a vida criminosa do acusado. Como a norma não diz qual espécie de atividade criminosa poderá ser qualquer uma, desde que, obviamente, não se trate de delitos culposos, que pressupõem ausência de vontade.

A norma visa a impedir a redução da pena para aquele que de forma habitual e deliberada pratica qualquer espécie de crime. Com efeito, aquele que faz da vida criminosa seu modo de vida não é merecedor do redutor. (Silva, César Dario Mariano da Lei de drogas comentada / César Dario Mariano da Silva. -- 2. ed. -- São Paulo : APMP - Associação Paulista do Ministério Público, 2016).

Em sentido semelhante:

“A habitualidade e o pertencimento a organizações criminosas deverão ser comprovados, não valendo a simples presunção. Não havendo prova nesse sentido, o condenado fará jus à redução de pena” (QUEIROZ, Paulo; LOPES, Marcus. Comentários à Lei de Drogas. 2016. p. 50).

Outrossim, a quantidade de drogas, por si só, não pode resultar na interpretação de que a ré faz do tráfico seu meio de vida ou integra organização criminosa, como já assentando. Nesse sentido, mais uma vez, convém colacionar o entendimento da jurisprudência, vejamos:

Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. LEI 11.343/2006. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. GRANDE QUANTIDADE DE MACONHA APREENDIDA (132,85 KG). DEDICAÇÃO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PACIENTE ABSOLVIDA PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONTRADIÇÃO ENTRE OS FUNDAMENTOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO ORDINÁRIO AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO EM PARTE.

I - A grande quantidade de entorpecente, apesar de não ter sido o único fundamento utilizado para afastar a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, foi, isoladamente, utilizado como elemento para presumir-se a participação da paciente em uma organização criminosa e, assim, negar-lhe o direito à minorante.

II - A quantidade de drogas não poderia, automaticamente, proporcionar o entendimento de que a paciente faria do tráfico seu meio de vida ou integraria uma organização criminosa. Ausência de fundamentação idônea, apta a justificar o afastamento da aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Precedentes.

III - É patente a contradição entre os fundamentos expendidos para absolver a paciente da acusação da prática do delito tipificado pelo art. 35 da Lei 11.343/2006 e aqueles utilizados para negar-lhe o direito à minorante constante do art. 33, § 4º, do mesmo diploma legal. Precedentes.

IV - Recurso ordinário ao qual se dá provimento, em parte, para reconhecer a incidência da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, e determinar que o juízo a quo, após definir o patamar de redução, recalcule a pena e proceda ao reexame do regime inicial do cumprimento da sanção e da substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, se preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal.

STF. RECURSO ORDINÁRIO E M HABEAS CORPUS 138.715 MATO GROSSO DO SUL.

Ainda, é preciso salientar que com a acusada não foi encontrado qualquer tipo de

armamento, ou quantia mais expressiva em dinheiro e o crime, ao que consta, não envolveu qualquer tipo de ameaça, violência ou intimidação. Ademais, a quantidade da droga já foi considerada por ocasião da valoração das circunstâncias judiciais.

Nesse sentido, o recente julgado do STJ:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. CIRCUNSTÂNCIAS QUE, POR SI SÓS, NÃO PERMITEM AFERIR A DEDICAÇÃO DO ACUSADO À ATIVIDADE CRIMINOSA E, PORTANTO, NÃO SE PRESTAM PARA JUSTIFICAR O AFASTAMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO OU MODULAR A FRAÇÃO DESSE BENEFÍCIO. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (RECURSO ESPECIAL Nº 1925096 - SP - RELATORA: MINISTRA LAURITA VAZ - Brasília, 02 de agosto de 2021). (grifos nossos).

No presente caso, contudo, à vista das circunstâncias específicas do caso, mesmo reconhecida a condição de mula, verifica-se que a ré atuou favorecendo um narcotráfico mais estruturado e de maior expressão. Diante disto, cabível a redução à razão de 1/2.

Nesse contexto, à míngua de outras causas modificadoras, fica a ré ELISANGELA MARIA DA SILVA definitivamente condenada ao crime de tráfico privilegiado à pena de 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, cumulada com 291 dias-multa, no mínimo legal, pena esta que torno definitiva.

Do regime inicial de cumprimento de pena e alternativas penais:

Não obstante tratar-se de crime de tráfico de drogas, afastada deve ser a regra inserta no art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, com a redação dada pela Lei nº 11.464/07, por determinar o cumprimento inicial da pena imposta por tráfico de entorpecentes, sempre no regime fechado, pois viola o princípio da individualização das penas, sendo certo que para a fixação de regime mais gravoso, necessário exigir-se sempre a devida motivação, ainda que se trate de crime hediondo ou equiparado. Nesse sentido:

PENA REGIME FECHADO INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 1º, § 1º, DA LEI Nº 8.072/1990. A imposição do regime inicial fechado, prevista na Lei de Crimes Hediondos, é inconstitucional, considerado o princípio da individualização da pena. Precedente: habeas corpus nº 111.840, relator o ministro Dias Toffoli, julgado pelo Pleno em 27 de junho de 2012, acórdão publicado no Diário da Justiça de 17 de dezembro de 2013. PENA TRÁFICO DE DROGAS SUBSTITUIÇÃO DA PRIVATIVA DA LIBERDADE PELA RESTRITIVA DE DIREITOS INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 44 DA LEI Nº 11.343/2006. A vedação à substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, prevista na Lei de Tóxicos, é inconstitucional, ante o princípio da individualização da pena. Precedente: habeas corpus nº 97.256, relator o ministro Carlos Ayres Britto, julgado em 1º de setembro de 2010 pelo Pleno, acórdão publicado no Diário da Justiça de 16 de dezembro imediato. PENA EXECUÇÃO REGIME E CUMPRIMENTO. Não se tratando de réu reincidente, ficando a pena no patamar de 2 anos e sendo as circunstâncias judiciais positivas, cumpre observar o regime aberto e apreciar a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos artigos 33 e 44 do Código Penal. (HC129714, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 11/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-086 DIVULG 25-04-2017 PUBLIC 26-04-2017) (grifos nossos)

Com essa convicção, resultante da interpretação da norma infraconstitucional ao influxo da Constituição da República, com base na pena aplicada, presente circunstância judicial negativa, nos termos do art. 33, §2º e §3º o regime inicial será o SEMIABERTO.

A acusada permanece presa desde 25/08/2021 (fl. 01). Contudo, deixo de aplicar o

disposto no §2º, do art. 387, do Código de Processo Penal, acrescido pela Lei nº 12736/12, uma vez que, mesmo computado o tempo em que a ré esteve presa provisoriamente, não haveria alteração do regime inicial de cumprimento de pena em virtude das específicas circunstâncias do cometimento do delito. Assim, a detração será realizada, no momento apropriado, pelo juízo da execução.

Não estão atendidas as condições previstas art. 44, inciso III e art. 77, "caput", inc. III, do Código Penal, uma vez que incide no caso uma circunstância judicial negativa, razão pela qual deixo de substituir a pena por restritiva de direitos.

Diante do regime inicial de pena fixado, mantenho a prisão cautelar da acusada, eis que presentes os requisitos que a ensejaram, os quais permanecem inalterados. Deste modo, nego o direito de recorrer em liberdade.

Após o trânsito em julgado da presente decisão condenatória, sendo mantida, determino:

- a) Lançamento do nome da condenada no Rol dos Culpados.
- b) Apuração dos valores das penas de multa aplicada à sentenciada.
- c) Comunicação à Justiça Eleitoral que a sentenciada encontra-se com seus direitos políticos suspensos, face ao disposto no artigo 15, III, da Constituição Federal.
- d) Por força do parágrafo 9º, do artigo 4º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno a ré a pagar a taxa judiciária de 100 (cem) UFESPs. Porém, atento aos elementos constantes do processo, defiro-lhe a gratuidade da justiça, de modo que a exigibilidade do tributo ficará suspensa enquanto perdurarem os embaraços que justificaram a concessão do benefício. Decorridos cinco anos da sentença final sem que as condições econômicas autorizem a cobrança da taxa, a obrigação estará prescrita, nos termos do artigo 12 da Lei n.º 1.060/50.
- e) Se for o caso, expeça-se certidão de honorários advocatícios ao(s) Defensor(es) nomeado(s) no grau previsto na tabela do convênio DPE/OAB, independentemente de requerimento ou nova determinação, assim que houver a interposição de recurso por qualquer das partes e forem apresentadas as razões ou contrarrazões recursais, conforme o caso, pelo defensor nomeado ou, na hipótese de ausência de recurso, após a certificação do trânsito em julgado.
- f) Com fundamento no art. 58, § 1º, da Lei nº 11.343/06, inexistente controvérsia acerca da qualidade e quantidade da droga, autorizo a incineração, preservada pequena porção para eventual contraprova, com comunicação à Autoridade Policial.

P. I. e C.

Arujá, 15 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA